

1510323-98.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510323-98.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510323-98.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3043428/2021 - 01º D.P. AMERICANA, 18133539 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY CLAUDIO CAMARGO DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

WESLEY CLÁUDIO CAMARGO DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, "caput" da Lei 11.343/06, porque, na data e local descritos na denúncia, tinha em depósito, para consumo pessoal, substância entorpecente a qual provoca dependência física e psíquica (3,3 gramas da droga conhecida como maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia de fls. 34/35, foi recebida em 26 de outubro de 2022.

O réu foi citado (fls. 57/58).

Durante a instrução, foi ouvida a testemunha de acusação, e o réu foi interrogado

(fls. 68/69).

Em memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 77/79), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se, o Doutor Defensor (fls. 82/95) requereu a absolvição pela ilegalidade da prova, ou a aplicação da pena de advertência.

Ante a apresentação de preliminar, os autos retornaram ao Ministério Público para manifestação (fls. 100/101).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A preliminar suscitada pela Douta Defesa deve ser afastada.

Com efeito, já é pacífico na jurisprudência a possibilidade do guarda municipal realizar a prisão, porque nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode realizar prisão em flagrante. Além disso, o direito à inviolabilidade do domicílio, revisto no artigo 5º, XI da Constituição Federal, possui exceção no próprio artigo, ao ressaltar os casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Como se vê, são quatro exceções: uma delas, a determinação judicial, mas neste caso somente durante o dia; as outras três não possuem limitação temporal, podem ser durante o dia ou mesmo durante a noite, basta que estejam ocorrendo naquele momento. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – Ação Penal – Preliminar – Alegação de nulidade da prisão em flagrante efetuada por integrantes da guarda municipal – Inocorrência – Qualquer pessoa, no exercício da cidadania, pode efetuar prisão em flagrante – Dicção do art. 301 do Código de Processo Penal – Conquanto a guarda municipal não esteja investida de atividade de polícia preventiva, pode atuar em caráter secundário na pacificação social, prevenção e inibição da prática delitiva, mormente quando ocorrida em locais e condições que estão sob sua esfera de proteção – Inteligência do art. 5º, incisos III, IV, V, XIV e XVI, da Lei nº 13.022/2014 – Preliminar afastada – (...). (TJSP; Apelação Criminal 1502519-56.2021.8.26.0544; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. (...). 4. Ordem denegada. (HC 129.932/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO

DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. (...). 2. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado no caso dos autos, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que possui outros registros criminais, já tendo sido, inclusive, condenada, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 5. (...). 9. Habeas corpus não conhecido. (HC 549.805/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020)

A presente demanda originou-se de realização de diligência policial de rotina para a verificação de ocorrência e preservação, e não trabalho investigativo por parte dos policiais. A indicação de que o local conhecido pelo tráfico de drogas, somada a localização de substância entorpecente, e a confirmação de uso por parte do réu, comprovam a legalidade dos atos perpetrados.

Verifica-se que não ocorreram diligências típicas de polícia, como busca domiciliar ou quebra de dados telemáticos, mas de realização de prisão em flagrante, ainda assim quando os servidores públicos municipais desempenhavam função regular, de patrulhamento em vias da cidade e praça pública.

Dessa forma, diversamente do sustentado, nenhum abuso, ou nulidade, ocorreu na diligência policial.

Por fim, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, "proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida; 'coisas achadas ou obtidas por meios criminosos' (art. 240, § 1º, b, do CPP); 'instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos' (art. 240, § 1º, c, do CPP); 'armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso' (art. 240, § 1º, d, do CPP); 'objetos necessários à prova de infração ou à defesa do autuado' (art. 240, § 1º, e, do CPP); 'cartas, abertas ou não, destinadas ao autuado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato' (art. 240, § 1º, f, do CPP); e 'qualquer elemento de convicção' (art. 240, § 1º, h, do CPP)".

A alegação de nulidade por ausência de justa causa para a revista não deve prosperar no presente caso. Conforme delimitado nos autos do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), pelo Superior Tribunal de Justiça, a busca deve ser, "baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência", o que resta presente, posto que os policiais localizaram a substância entorpecente.

No mais, a fundada suspeita, considerando, também, que o local é conhecido pelo tráfico, restou comprovada pela apreensão de drogas, cuja propriedade foi

confirmada pelo réu.

Desta forma, a conduta dos policiais restou fundada na justa causa, em especial pela necessidade de imediata cessação da conduta criminosa, não se tratando de medida ilegal e abusiva.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelo laudo de fls. 28/30.

A autoria é indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu confessou a prática do delito, alegando fazer uso de maconha. Disse que mora perto da praça e foi ao local para compra a droga para uso próprio, e após foi abordado pelos policiais.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

“Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: “A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

“É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem” (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, a guarda municipal disse que realizavam patrulhamento, durante a “operação saturação”, tendo em vista a ocorrência de problemas com tráfico e drogas na praça do bairro. Informou, ainda, que o réu e outros dois indivíduos foram abordados, sendo que como réu foi encontrada a porção de maconha, e próximo a eles outras porções de entorpecentes.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos

mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas ("Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

Não procedem as alegações da defesa quanto à imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).(...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

A conduta relativa ao porte de entorpecentes para o consumo pessoal é típica e antijurídica, não se vislumbrando violação a quaisquer princípios constitucionais.

Não é somente o uso propriamente que caracteriza o delito, mas igualmente a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para essa finalidade, sendo que o bem jurídico protegido é a saúde pública, a não apenas a saúde do usuário.

As provas colhidas são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

Desta forma, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que o réu, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Destarte, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu é reincidente (Certidão de fls. 18/20), verificando-se a aplicação do parágrafo 4º, do art. 28, da referida Lei.

Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do réu em 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, prevista no inciso II, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006, considerando-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP).

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu WESLEY CLÁUDIO CAMARGO DIAS à pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, como incurso no artigo 28, inc. II, da Lei nº. 11.343/2006.
P.I.C.

Americana, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA